

1519813-02.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... portanto, que a conduta de praticar tráfico de drogas durante a situação de calamidade pública representa risco ainda maior à saúde pública, pois, não atenta apenas contra a saúde daquele que consome a droga objeto material do crime de tráfico, mas, primordialmente, promove aglomeração de pessoas no local da prática do crime de tráfico, concorrendo para disseminação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2127-

9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1519813-02.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519813-02.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wesley do Amapro Lucas

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Cesar Muller Valente

Vistos, etc.

Wesley do Amparo Lucas, qualificado à fl. 12, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, e no artigo 163, parágrafo único, inciso III, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 17h08, na Alameda Cleveland, altura do nº 374, bairro de Santa Cecília, nesta cidade e Comarca de São Paulo, em situação de calamidade pública de saúde causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19), trazia consigo para a entrega e consumo de terceiros, 7 porções de tetrahidrocannabinol, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 17,7g, 3 pedras de crack, com peso líquido de 47,8g e 54 porções de cocaína com peso líquido de 23,3g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo de constatação de fls. 25/28. Consta, ainda, do incluso inquérito policial que no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 17h08, na Alameda Cleveland, altura do nº 374, Santa Cecília, São Paulo, em situação de

calamidade pública de saúde causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19), deteriorou o patrimônio do Município de São Paulo, consubstanciado no rompimento do vidro traseiro do veículo automotor Renault Duster, ano/modelo 2019/2020, de cor branca e placas DSI-1524.

Segundo o apurado, na data e local descritos acima, Wesley, aproveitando-se do menor tráfego de transeuntes, e diminuto policiamento ocasionado pela pandemia do vírus Covid 19, trazia consigo os entorpecentes acima descritos, destinados à venda e distribuição a terceiros, custodiados no interior de uma caixa de som. A autoria do presente crime somente foi descoberta, porque guardas municipais, em patrulhamento pela Alameda Cleveland, decidiram por abordar o réu, na altura do numeral 374, ao constatarem que ele, ao presenciar a aproximação dos guardas civis, esboçou exacerbado nervosismo. Em revista pessoal, no interior de uma caixinha de som, que o réu trazia consigo, foi localizado o entorpecente acima listado. Ocorre que Wesley era foragido da justiça, fls. 33/35, por delitos praticados no ano de 2019, e percebendo que seria autuado em flagrante delito e conduzido ao Distrito Policial, investiu contra a viatura da Guarda Civil, ocasionando a quebra do vidro traseiro do automóvel Renault Duster, ano/modelo 2019/2020, de cor branca e placas DSI-1524. Autuado em flagrante delito e conduzido ao Distrito Policial, em interrogatório formal perante a digna Autoridade Policial, Wesley assumiu que trazia o entorpecente apreendido junto a si, conforme termo de interrogatório de fls. 09.

Denúncia recebida em 24 de agosto de 2021, citado o réu (fl. 106), a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fls. 111), seguindo-se a instrução, com duas testemunhas e interrogatório ao final.

Em alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia, afastando-se a causa especial de redução de pena em função de processo anterior que permaneceu suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal até a data do flagrante.

A Defensoria Pública sustentou nulidade do flagrante praticado por guardas municipais, insuficiência de provas para condenação, subsidiariamente, aplicação de pena mínima, em regime inicial menos gravoso, com substituição por penas restritivas de direitos.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

Afasto a arguição preliminar de nulidade do flagrante formulada pela defesa, reportando-me ao disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal, que confere a qualquer pessoa a iniciativa para prender criminosos em flagrante delito, baseado em recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 5a Turma, no AgRg no HC 684062/SP: Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDAS MUNICIPAIS. ILEGALIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE AUTORIZADA. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA. DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADAS.

É assente nesta Corte Superior a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes" (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/05/2017).

Auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo de constatação de fls. 25/28 indicam 7 porções de tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 17,7g, 3 pedras de crack, com peso líquido de 47,8g e 54 porções de cocaína com peso líquido de 23,3g.

Laudo de exame químico-toxicológico de fls. 137/139 indica resultados positivos para tetrahydrocannabinol e cocaína.

Laudo pericial de vistoria da viatura da Guarda Municipal de fls. 132/135 descreve

danos aparentes de aspecto recente: rompimento do vidro da tampa do porta-malas. Está provada a materialidade delitiva, tal como consta na denúncia.

Em fase inquisitiva, os guardas municipais Francislane Romualdo da Silva Pires e Luiz Fernando Conceição relataram que estavam em patrulhamento no local dos fatos, quando viram que Wesley, ao ver a Guarda, demonstrou nervosismo. Assim, decidiram pela abordagem, e, com ele, dentro de um objeto que parecia uma caixinha de som, encontraram diversos tipos de entorpecentes, que parecia ser Mesclado, Maconha e Cocaína, em quantidade considerável. Acrescentaram ainda que Wesley, ao perceber que seria preso, resistiu e investiu contra a viatura da Guarda Civil, quebrando o vidro traseiro.

O réu, interrogado na fase extrajudicial, apenas admitiu que carregava as drogas, sem tecer maiores detalhes sobre sua conduta.

Em audiência de instrução:

Francislane Romualdo da Silva Pires, guarda civil municipal, relatou que o réu caminhava em direção ao movimento de usuários de drogas nas imediações, quando se deparou com a viatura e retornou, decidindo abordá-lo, ele trazia uma caixa de música, que ele não queria entregar, dentro da qual havia duas ou três pedras de "crack", papелotes de cocaína e papелotes de "mesclado", não se recorda se ele trazia dinheiro, então, ele ficou nervoso e agarrou-se numa grade, começou a subir na viatura e quebrou o vidro traseiro, sendo contido a força, e a princípio ele nada alegou sobre a procedência ou destinação das drogas apreendidas.

Luiz Fernando Conceição, guarda civil municipal, relatou que o réu caminhava em via pública, deparando-se com a viatura, e demonstrou nervosismo, e reagiu à abordagem, trazendo nas mãos um rádio, que não queria soltar, chutou e quebrou o vidro traseiro da viatura, resistindo à prisão, e dentro da caixa de som que ele trazia havia drogas. Era uma pequena caixa de som com substâncias variadas, parte embalada e parte solta, crack e cocaína. Não foi apreendida quantia em dinheiro.

Anteriormente à abordagem não foram presenciados atos de mercancia ilícita. Ao ser detido o réu insistiu em negar a posse das drogas. Posteriormente foi constatado que ele se encontrava foragido. Identificou o réu em audiência.

Interrogado ao final da instrução, o réu Wesley do Amparo Lucas disse que seguia em direção ao "fluxo de usuários", onde costuma permanecer, quando alguém lhe entregou uma caixa de som e ofereceu duas pedras de crack, para que passasse pelos guardas, e acabou quebrando o vidro da viatura ao ser abordado pelos guardas ao tentar passar por trás da viatura.

A versão do acusado não se sustenta, pois, ao notar que seria abordado, ele logo demonstrou nervosismo e tentou se esquivar dos guardas municipais, evidenciando que estava ciente de que trazia consigo algo de ilícito, e naquela localidade, em meio a traficantes e usuários de drogas, evidentemente sabia que transportava drogas, tanto que chegou a admitir em seu interrogatório judicial, "cheguei a suspeitar mais aceitei".

Não há outra explicação possível para a conduta do réu, porque ele caminhava em direção ao "fluxo" de usuários de drogas, em região de alta incidência de tráfico de drogas, conhecida como "cracolândia", trazendo consigo uma caixa de som carregada com drogas.

Neste contexto, a prova da apreensão das drogas resulta dos relatos dos agentes públicos, contra os quais não consta nenhum outro elemento de prova, sendo que, se de fato havia mais alguém que pudesse ser ouvido em audiência para contrariá-los, cumpria à defesa arrolar como testemunha, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal. Baseando-se em tais provas, sobre a validade dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, ao contrário do que sustentou a defesa em alegações finais, devem ser acolhidos como elementos de prova, eis que uníssomos e coerentes com o teor do auto de prisão em flagrante, prevalecendo a presunção de legalidade e veracidade de que se revestem os atos dos agentes públicos, constituindo ônus da defesa a prova em sentido contrário, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, e nesta ação penal não se tem qualquer indício de suspeição ou ilegalidade que possa macular o valor de tais depoimentos. Reporto-me ao entendimento jurisprudencial: Prova criminal - Testemunha - Tráfico de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Inexistência de razão concreta para a

suspeição - Relato firme e coerente - Apreensão da droga, ademais, presenciada por testemunha alheia aos quadros da polícia - Recurso não provido - JTJ 241/313. Crime contra a saúde pública - Prova criminal - Depoimento de policial participante de diligência do flagrante - Testemunho coerente e seguro - Validade - RT 595/423.

E quanto ao elemento subjetivo do crime atribuído ao réu, inequivocamente, trazer consigo dezenas de porções de drogas variadas caracteriza prova de mercancia ilícita, mesmo porque, o próprio réu afastou a possibilidade da droga destinar-se a consumo pessoal, supostamente imaginando que ganharia depois apenas duas porções de crack do total de drogas que transportava a mando de terceiro não identificado.

Procedente a ação penal, nos termos da denúncia. Passo ao cálculo das penas, nos termos do artigo 42 da Lei 11343/06, e artigo 68 do Código Penal.

Wesley do Amparo Lucas responde a outro processo criminal, por outra modalidade de crime, e não ostenta condenação anterior, que não deve ser considerado para efeitos dos artigos 59 e 63 do Código Penal, a teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

A quantidade de entorpecentes apreendidos, menos de cem gramas ao todo, não é suficiente para ser considerada como circunstância judicial desfavorável a impor majoração da pena base, que fica mantida no mínimo legal de cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa. Presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea J, do Código Penal, prevê circunstância objetiva da conduta, consistente em praticar crime em "qualquer calamidade pública", isto é, quem praticar crime em tal circunstância, independentemente de intensão, receberá tratamento legal diferenciado. O Decreto número 64879, de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo decorrente da pandemia do Covid-19, foi largamente divulgado por todos os meios de comunicação, de conhecimento, sendo inviável alegar ignorância da situação atual de pandemia. Inequivoco, portanto, que a conduta de praticar tráfico de drogas durante a situação de calamidade pública representa risco ainda maior à saúde pública, pois, não atenta apenas contra a saúde daquele que consome a droga objeto material do crime de tráfico, mas, primordialmente, promove aglomeração de pessoas no local da prática do crime de tráfico, concorrendo para disseminação da doença e contágio coletivo, risco que o traficante assumiu e será apenado proporcionalmente à gravidade da conduta criminosa, impondo-se acréscimo de 1/5 sobre a pena base, em seis anos de reclusão e seiscentos dias multa. Pela causa legal de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33, tratando-se de réu primário e não havendo notícia de que integre organização criminosa, aplica-se a redução de 2/3, totalizando para o crime de tráfico de drogas as penas de dois anos de reclusão e duzentos dias multa. Para o crime de dano ao patrimônio público, as circunstâncias da conduta não extrapolam as elementares do tipo penal, prevalecendo a pena base em patamar mínimo legal de seis meses de detenção e dez dias multa, acrescida de 1/6 em função da circunstância agravante de crime praticado durante situação de calamidade pública, em sete meses de detenção e onze dias multa.

Pela regra do artigo 69 do Código Penal, aplicam-se cumulativamente as penas, cumprindo-se inicialmente a pena de reclusão.

Os dias multa serão calculados pelo valor unitário mínimo legal, não havendo prova da condição econômica dos réus, nos termos do artigo 60 do Código Penal.

De acordo com a recente modificação legislativa, introduzida pela Lei 13964 de 2019, que em seu artigo 40, na parte em que trata de execução de pena, acrescentando o parágrafo 5o ao artigo 112 da Lei 7210, afastou expressamente o tratamento legal diferenciado que antes equiparava o denominado tráfico privilegiado a crime hediondo, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8072/90, passando a ser considerado o disposto no artigo 33, parágrafo segundo, para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, em função da quantidade de pena aplicada, que no caso será o regime inicial aberto.

Pelos mesmos fundamentos, tratando-se de réu primário, é cabível substituição de suas penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em jornadas semanais não inferiores a oito horas, e limitação de fim de semana, ambas com o mesmo prazo da pena substituída, a serem individualizadas em posterior fase de execução.

Do exposto, julgo procedente a ação penal, para condenar Wesley do Amparo Lucas, qualificado à fl. 12, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, e no artigo 163, parágrafo único, inciso III, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, às penas de dois anos de reclusão, sete meses de detenção, a serem cumpridas sucessivamente, em regime inicial aberto, substituídas por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em jornadas semanais não inferiores a oito horas, e limitação de fim de semana, com o mesmo prazo das penas somadas, em dois anos e sete meses, a serem individualizadas em posterior fase de execução, e multa penal cumulativa de duzentos e onze dias multa pela fração legal mínima.

Ao trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à Justiça Eleitoral nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de cem ufesp (artigo 4º, § 9º, "a", Lei Estadual 11.608/2003), suspensa a exigibilidade enquanto defendido pela Defensoria Pública.

Não imposta antecipadamente pena privativa de liberdade, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados, registre-se.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA